

1503905-62.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... demonstrado que a droga lhe pertencia e que comandava o tráfico no local.

É verdade que documentos pessoais foram encontrados no veículo e que o mesmo servia de esconderijo do dinheiro arrecadado com o tráfico de entorpecente, sendo que toda a alegação de que o veículo não funcionava e que a chave do mesmo fora irregularmente utilizada por Leandro não tem base probatória, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503905-62.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503905-62.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089294/2022 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 24008174 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 115/22/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2089294 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO TOME GARDIANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

LEANDRO TOME GARDIANO e WELKER JUNIOR CANHADA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 31 de março de 2022, por volta das 16h00, na Rua Sorocaba, 556, São Francisco, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os acusados previamente ajustados, com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si e com o adolescente Saymon Camillo de Oliveira, traziam consigo drogas, consistentes em 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, para fins de comércio

ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 13/15.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Saymon, traziam consigo as drogas supracitadas, para comércio com terceiros, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar. Policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que uma casa abandonada situada na Rua Sorocaba estaria sendo utilizada para a prática do tráfico de drogas. Em posse dessa informação, se deslocaram até o local, oportunidade em que avistaram Leandro e Saymon saindo do imóvel. Ao notar a presença da viatura, ambos tentaram se evadir, motivando a abordagem. Em busca pessoal, foram encontrados, na posse do adolescente, 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína. Com o denunciado Leandro, nada de ilícito foi localizado, apenas a chave de um veículo. Indagados, Saymon confessou a traficância, indicando que o dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes ficava guardado no interior do veículo VW/Golf que se encontrava estacionado no local, cuja chave estava em posse de Leandro. Por sua vez, Leandro afirmou que apenas estava incumbido de ficar com a chave do automóvel, cuidando para que o adolescente guardasse os valores provenientes do tráfico. Ao revistar o carro, os policiais encontraram R\$210,00 (duzentos e dez reais) em notas fracionadas e diversos documentos pertencentes aos denunciados Leandro e Welker. Após investigações, apurou-se que o veículo VW/Golf é de propriedade de Welker, sendo o denunciado "gerente" das "biqueiras" situadas no bairro Santa Rosa, bem como que Leandro e o adolescente Saymon agiam sob seu comando naquela localidade.

Denúncia (fls. 95/98).

Defesa prévia (fls. 149/169 - Welker e 173/175 - Leandro).

Recebimento da denúncia (fls. 187/188).

Conversão da prisão em flagrante em preventiva de Leandro decretada (fls. 53/57).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia e em regime fechado (fls. 292/299).

Em alegações finais, a defesa de WELKER pleiteou sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, liberando-se o veículo apreendido nos autos, por não haver prova de ter sido o mesmo objeto de envolvimento nos delitos apontados (fls. 304/337).

Em alegações finais, a defesa de LEANDRO pleiteou seja a presente ação penal julgada totalmente improcedente, com sua absolvição, nos termos do inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal (fls. 338/341).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha M.P.S. (fl. 03), policial militar, disse que receberam denúncia anônima de que em uma casa abandonada, situada na Rua Sorocaba, 556, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, diante a informação se deslocaram até o local, onde observaram que havia dois indivíduos estavam saindo da citada residência, com a aproximação da viatura policial ambos indivíduos se evadiram rapidamente mas sendo abordados logo em seguida. Foi realizada a busca pessoal no adolescente infrator identificado como sendo SAYMON CAMILLO DE OLIVEIRA, sendo localizada em seu poder uma bucha contendo 35 pinos de cocaína. Na busca pessoal realizada no autuado LEANDRO TOME GARDIANO, nada de ilícito foi localizado em seu poder apenas uma chave de um veículo. Indagado o adolescente infrator SAYMON informalmente disse que estava traficando naquele local e que guardava o dinheiro da venda das drogas em um veículo VW/Golf. Ao ser indagado LEANDRO disse que apenas ficava na posse da chave do veículo onde destrava para abrir e fechar o veículo para que SAYMON guardasse o dinheiro da venda das drogas no interior do carro. Diante as alegações de ambos a equipe se dirigiu até o veículo VW/Golf de placa JNU0C89, indicado por eles onde localizaram a quantia de R\$210,00 no interior do carro, estando no console do mesmo. Diante aos fatos foi emanada voz de prisão ao autuado LEANDRO TOME GARDIANO, e voz de apreensão ao adolescente infrator SAYMON CAMILLO DE OLIVEIRA, ambos foram cientificados quanto a seus direitos constitucionais e encaminhados até esta delegacia especializada, onde a autoridade policial ratificou a prisão de LEANDRO e a apreensão de SAYMON.

A testemunha J.C.S. (fl. 04), policial militar, disse que acompanhava o militar Marcos na checagem da denúncia na casa abandonada situada na Rua Sorocaba, 556 estaria ocorrendo o tráfico de drogas. No local observaram que haviam dois indivíduos saindo da casa, os quais se evadiram, mas logo em seguida foram abordados. Em revista pessoal com o adolescente foi localizado uma bucha com 35 pinos de cocaína, indagado o mesmo alegou que traficava no local e guardava o dinheiro em um carro. Em revista pessoal no autuado LEANDRO TOME GARDIANO foi localizado a chave de um veículo, ao ser indagado informou que utilizava a chave do veículo acionando para abrir e fechá-lo auxiliando SAYMON para que ele guardasse o dinheiro da venda das drogas. Diante aos fatos foi emanada voz de prisão ao autuado e voz de apreensão ao adolescente sendo ambos apresentando nesta DIG.

A testemunha menor S.C.O. (fl. 07) disse que na data de hoje estava subindo o pontilhão do Bairro Santa Rosa, quando foi abordado por policiais militares, perguntaram ao declarante onde estava a droga, informando que não tinha nada, disseram que ele seria apreendido. Colocaram o declarante na viatura e trouxeram para esta delegacia, afirma que pegaram uma bucha de droga no interior da viatura. Não sabe informar que é o outro indivíduo que foi preso e não o conhece, não sabe informar também sobre o veículo o qual foi apreendido. Afirma que não havia nada em seu poder e que está sendo forjado. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas e não sabe o motivo porque está sendo apreendido.

A testemunha K.R.I. (fls. 76) disse que é proprietária do veículo VW/GOLF de placa JNU0C89, o qual foi adquirido pela declarante no dia 24/10/2021, pagando a quantia de R\$10.000,00 nas condições que se encontrava naquela época, pois o mesmo encontra-se danificado, sendo os amortecedores e outras coisas que não sabe informar. Esclarece que o veículo foi adquirido com os ganhos provenientes de seu labor, sendo que exerce a profissão de cuidadora de idosos e manicure. Em relação aos fatos esclarece que tomou conhecimento que seu veículo foi apreendido pela polícia militar por vizinhos. Afirma que o veículo fica na garagem e posteriormente na frente da casa de sua sobrinha, pois a casa da declarante está em reforma e ela não possui garagem em sua residência. Ressalta que toda manhã seu esposo antes de ir trabalhar se dirige até a casa de sua sobrinha, onde retira o veículo da garagem e colocando na frente do imóvel, deixando a chave na caixa do correio da casa de sua sobrinha. Esclarece que sua sobrinha Viviane Cristina Canhada dos Santos reside

na Rua Sorocaba, 540, por esse motivo o veículo estava naquele local. Em relação a Leandro o qual foi preso pelos policiais militares, não o conhece e não sabe o motivo que ele estaria na posse do veículo. Afirmar que seu veículo não é utilizado para a prática de tráfico de drogas, pois não há condições de circulação na via pública devido os amortecedores estarem quebrados e as peças para a troca encontram-se no interior do carro. Afirmar que os amortecedores e outras peças as quais se encontram no interior do automóvel, foram adquiridos através do mercado livre. A declarante está aguardando para fazer a troca das peças, pois está juntando o dinheiro para fazer o conserto devido o alto valor da mão de obra, pois há outras coisas para ser consertado, inclusive não realizou a transferência, pois há algumas pendências em relação ao veículo, mas afirma que a comunicação de venda está feita, inclusive apresenta cópia do CRV reconhecido firma. A declarante não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não sabe o porquê seu veículo foi apreendido pois não havia nada de ilícito em seu interior. Afirmar novamente que seu carro não possui condições de circulação na via pública, pois está com os amortecedores quebrados, sendo necessário o seu conserto para que ele possa voltar a ser utilizado. Neste ato deseja a liberação de seu veículo, devido ser a proprietária e o mesmo não ter relação com nenhum dos envolvidos no presente BO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

O acusado L.T.G. (fl. 05) disse que na data de hoje estava se dirigindo até a Rua Mococa para comprar dois pinos de crack, quando foi abordado por policiais militares. Observou que um indivíduo o qual desconhece evadiu-se rapidamente. Os policiais disseram que ele estava correndo, mas o interrogando informou que não correu, um dos policiais disse que iria forjá-lo com a droga do interior da viatura. Afirmar que levaram o interrogando até um local onde havia um terreno e um veículo, disseram que o veículo era dele, mas o interrogando não sabe informar de quem é o veículo. Após os fatos o interrogando foi conduzido até esta delegacia especializada. Afirmar que a versão dos policiais militares não condiz com o que realmente aconteceu e estão forjando o interrogando. Não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e afirma que os policiais militares ficaram com seus pertences.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02); Boletim de Ocorrência (fls. 08/10); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11); Laudo de Constatação (fls. 13/15) e Exame Químico Toxicológico (fls. 100/102); e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado Leandro, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

A busca pessoal exige fundada suspeita.

O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa.

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do

tirocínio policial, mas também pela conduta dos acusados que tentaram se evadir ao perceberem a presença dos policiais no local dos fatos, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A testemunha J.E.C. disse que não participou da ocorrência e que a polícia militar apresentou os réus. Foi apreendido um veículo Golf na ocorrência. A chave estaria na posse de Leandro que estaria guardando o dinheiro fruto do tráfico no veículo. O veículo pertencia a Welker que comandava a biqueira no Santa Rosa e estaria usando o bem para traficância. Sobre Leandro não tinham informações anteriores. Dentro do veículo foram encontrados vários documentos de Welker e alguns documentos de Leandro. A dona do veículo era Katia. Teve contato com Leandro e Saymon na delegacia. Leandro disse que era usuário e negou a posse de drogas e o menor disse que saiu correndo, mas a polícia o pegou e não disse nada sobre drogas. Saymon foi pego recentemente por eles novamente no bairro Santa Rosa. Leandro estava com a chave do veículo e por isso foi preso. Ele negou a posse da chave. Welker já vinha sendo alvo de investigação faz tempo. Nunca viu Leandro e Welker juntos. Não sabe se Welker foi ouvido na delegacia, pois é investigador e não do cartório da delegacia.

A testemunha M.P.S., policial militar, disse que participou da prisão dos réus. Foram acionados por morador que no local estava ocorrendo tráfico. No local viram 2 indivíduos saindo de uma residência abandonada que não tinha nem portão. Ficaram nervosos e tentaram correr para dentro da casa. Eles saíram pulando por diversas casas. Abordou Leandro e Sales abordou o Saymon. Com Leandro foi encontrada a chave do veículo em seu bolso, veículo Golf. Com Saymon foram encontradas drogas. O veículo estava estacionado na rua da casa abandonada. Leandro disse que ficava com as chaves para travar e destravar o carro quando o menor tinha que guardar dinheiro no carro. Leandro disse que Juninho (Welker) era dono do veículo e de mais três biqueiras no bairro. Saymon confessou que estava vendendo entorpecentes ali. Os 35 pinos de cocaína estavam com Saymon. O menor vendia, Leandro abria e fechava o carro para guardar o dinheiro e Welker era o dono da biqueira e do carro. No interior do veículo havia documentos de Leandro e Welker e dinheiro também, os R\$ 210,00, em notas variadas e picadas. No entorno ninguém manifestou a posse do veículo. A chave foi testada no veículo. Ela travava e destravava o carro. Também ligava a parte motora. O veículo estava funcionando e estava no lado oposto da rua da casa, estacionado.

A testemunha J.C.S., policial militar, disse que em patrulhamento pelo bairro, foram acionados por populares informando que em residência abandonada estava ocorrendo o tráfico de drogas. No local, viram dois indivíduos que tentaram se evadir. Com Leandro foi encontrada a chave do veículo e com Saymon drogas, cocaína. Saymon confessou a traficância e Leandro disse que abria o veículo para Saymon guardar o dinheiro da traficância. No carro havia documentos de Leandro e Welker. Não conhecia nenhum dos abordados. Leandro tentou correr quando viu a viatura. Os 210 reais eram em cédulas variadas/picadas. Os documentos foram encontrados no veículo no local da apreensão.

A testemunha R.F.D disse que conhece Welker, pois trabalha com a irmã dele. Ele trabalha de descarregador de caminhão esporadicamente. Neste dia, descarregaram um container. A empresa se chama transportadora Giacomini. Ele é trabalhador e todos gostam dele na empresa. O veículo Golf pertence à Kátia, que ficava parado, pois os documentos estavam atrasados e tinha que arrumar o veículo. Kátia é a tia de Welker. Não sabe se o carro pedia andar, sabe que os documentos estavam atrasados. Ao lado da casa da irmã do réu Welker tem uma casa abandonada. Conhece Leandro e

ele é viciado.

O acusado L.T.G. disse que foi abordado e apresentou seu livramento condicional. O levaram dois quarteirões do local da abordagem, rasgaram seu livramento condicional e colocaram a chave do carro no seu bolso. A droga não lhe pertencia. Não conhece Welker. Comprava droga de Saymon para consumo. Estava no local para comprar droga para o seu consumo. É pedreiro e estava trabalhando por conta. É usuário de crack. Comprava droga direto naquele local. Eles vendem crack.

O acusado W.J.C. disse que foi descarregar o container. O veículo é da sua tia Kátia. Ele fica parado do outro lado da rua, quase de frente da casa de sua irmã e está com o documento atrasado e com amortecedor quebrado. Desconhece de quem era a droga. Conhece Leandro que é filho de sua tia de Catiguá. Trabalha em transportadora e fica muito fora. Sua irmã mora na rua Sorocaba. Não morou com sua irmã. Tem família, pois é casado. Já foi processado por tráfico de drogas em 2017. Desconhece documento do Leandro no veículo. Tinha documento do declarante que era cartão cidadão e carteira de vacinação de covid. Seu tio pegou esse carro no mês 2 e o levou para tomar vacina na Rua Pará e no centro para sacar dinheiro no Banco. Kátia é mulher de seu tio. Ela tem recibo de compra e venda do veículo, datado e preenchido. Não conhece o menor Saymon.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Quanto ao veículo, conforme documento de fls. 83/85 (B0), foram encontrados dentro do veículo apreendido: carteira de reservista, documento PIS, documento de decisão e de livramento condicional, título de eleitor, todos de Leandro; Cartão bancário da CEF, comprovante de vacinação, dois recibos de pagamentos de salários, carta de protesto de letras e títulos, NIS/PIS, todos de Welker.

Do que consta dos autos e do que foi produzido pelos réus e testemunhas:

1 - o veículo passa a noite na garagem de Viviane, sobrinha de Kátia, pois sendo essa, sua casa está em reforma e não pode acomodar o veículo. Pela manhã o esposo de Katia retira o veículo da casa de Viviane e o coloca na rua, deixando as chaves na caixa dos correios de Viviane.

Dessa declaração, temos que o veículo funciona, pois do contrário, não seria retirado da garagem de Viviane e posto na rua todas as manhãs.

As chaves ficam na caixa de correios de Viviane, não sendo explicado por Kátia o porquê disso. Ora, as chaves deveriam estar com Kátia e não em uma caixa de correio na qual qualquer pessoa pode ter acesso, ainda mais se o seu esposo, todos os dias, movimenta o veículo.

2 - segundo relato de Welker em juízo, havia documento dele no veículo, que eram seu cartão cidadão e sua carteira de vacinação de covid, pois seu tio, esposo de Kátia, pegou esse carro no mês 2 e o levou para tomar vacina na Rua Pará e no

centro para sacar dinheiro no Banco.

Dessas alegações temos novamente a comprovação de que o carro funcionava, já que usado pelo tio de Welker, inclusive para levar o réu a lugares. Temos ainda a comprovação de que havia documentos de Welker no veículo.

Em suma: o carro funcionava, havia dentro dele documentos de Welker e de Leandro. O automóvel era instrumento utilizado pelos acusados para a prática do tráfico de drogas. Inclusive suas chaves ficavam dentro da caixa de correio da Sra. Viviane, sobrinha da suposta proprietária do veículo Sra. Kátia, tia do réu Welker que é primo do réu Leandro, com quem foram encontradas as chaves do veículo retro, no dia da abordagem.

QUANTO AO RÉU WELKER:

Embora tenha se esforçado para comprovar que trabalhava formalmente no momento da abordagem policial, fato é que a investigação produzida inicial apontou que o mesmo era o gerente da biqueira em que o adolescente e Leandro estavam dividindo tarefas, sendo que o adolescente trazia a droga consigo e Leandro facilitava o acesso ao veículo, destravando-o, para que o dinheiro fosse depositado no mesmo.

Contudo, a prova é frágil para o decreto condenatório de Welker, vez que apesar da lógica nos fatos articulados na peça de ingresso, não restou cabalmente demonstrado que a droga lhe pertencia e que comandava o tráfico no local.

É verdade que documentos pessoais foram encontrados no veículo e que o mesmo servia de esconderijo do dinheiro arrecadado com o tráfico de entorpecente, sendo que toda a alegação de que o veículo não funcionava e que a chave do mesmo fora irregularmente utilizada por Leandro não tem base probatória, mas para a condenação, exige-se prova concreta, o que não ocorreu.

Se investigação existia, não houve minimamente seu apontamento nos autos. Deve-se consignar que não estava no momento da prisão em flagrante e toda a base acusatória se finca nos documentos pessoais do mesmo e notícias de investigação policial, nada mais.

Sem prova concreta de sua participação no tráfico em discussão nos autos, a absolvição é medida que se impõe.

QUANTO AO RÉU LEANDRO:

Primeiramente nota-se Welker afirmou que Leandro é seu primo, filho de sua tia de Catiguá. Já Leandro, nas declarações confusas que deu em juízo, disse não conhecer Welker.

Nesse ponto vemos uma contradição nos dois depoimentos.

Outro ponto controverso no depoimento de Leandro foi quando disse que os policiais rasgaram seu documento de condicional, mas tal documento foi apresentado na delegacia, conforme fls. 84.

Leandro foi abordado com as chaves do veículo GOLF no bolso e, embora diga que os policiais forjaram as chaves com ele, essa alegação não tem respaldo probatório, uma vez que conforme afirmado por Kátia, as chaves do veículo ficavam na caixa de correio de sua sobrinha Viviane. Não havia como os policiais pegarem tal chave da caixa do correio de Viviane e forjá-la com Leandro.

Demais disso, se interesse em prejudicá-lo houvesse, não diriam os policiais que

nada de ilícito foi encontrado inicialmente com o réu. Somente após o adolescente confessar informalmente a traficância e descrever a conduta adotada é que destravaram o veículo que estava próximo ao local e dentro dele encontrado o dinheiro proveniente do tráfico ilícito de entorpecente, além dos documentos pessoais dos réus.

Não resta dúvida que o réu Leandro permanecia com as chaves do veículo para facilitar o acesso do adolescente para guardar o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas.

"Para a caracterização do concurso de pessoas, basta a adesão voluntária, antes da consumação, à conduta criminosa e a cooperação no sentido de realização do tipo penal, senão irrelevante a existência de prévio acordo" (TJMG, AC 1.0390.06.014669-8/001, Rel. Des. Hécio Valentim, DJ 11/5/2009).

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010)

A quantidade de droga não denota a finalidade de mero consumo próprio, em especial porque pairava notícia de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no local, o que motivou a diligência policial.

Quanto ao artigo art. 40, VI, da Lei 11.343/06: "Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe. Justifica-se o recrudesimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimputabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação." (HC n. 411.340/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 26/2/2018).

Veja que o tipo em comento destaca os verbos envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, independentemente de anterior corrupção do menor, visto que se a intenção for esta, estar-se-ia diante do tipo descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, cujos verbos são corromper ou facilitar a corrupção.

Para ilustrar: "Para a configuração da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não importa se o adolescente envolvido na prática da mercancia ilícita não era neófito no mundo do crime". (AgRg no HC 739533 / SP).

Como a descrição típica é claramente formal, basta a participação da criança ou do adolescente para a sua incidência, o que restou demonstrado nos autos.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, os réus eram imputáveis na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

Fixo a pena do acusado LEANDRO TOME GARDIANO.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 136/142). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração. A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, mas em razão dos maus antecedentes, fixo-lhe a pena-base acima no mínimo legal, em 05 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, já que foi definitivamente condenado nos autos n. 0001238-53.2018.8.26.0154 e 0001891-29.2015.8.26.0132 (fl. 136), pelo crime de tráfico de drogas e furto respectivamente.

Dessa forma, agravo a pena de 1/5, tornando a pena intermediária em 06 anos, 07 meses e 6 dias de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, aumento a pena de 1/6, totalizando 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, mas ostenta maus antecedente, motivo pelo qual a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 650 dias-multa.

No mais, não há prova da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

Estamos diante da reincidência específica, o que inibe a substituição, vez que os requisitos devem estar presentes cumulativamente.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que a condenação é superior a 2 anos (art. 77, caput, do CP), bem como é reincidente específico (art. 77, I, do CP).

Por tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado LEANDRO TOME GARDIANO como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à reprimenda de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato, bem como para ABSOLVER o acusado WELKER JUNIOR CANHADA da imputação descrita no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Além disso, a prisão preventiva de Leandro (art. 387, parágrafo único do CPP) foi decretada e mantida durante o processo (fls. 54/57) e persistem os motivos cautelares (ordem pública) que fundamentaram a prisão, motivo pelo qual não há se falar em revogação da prisão processual.

Assim, considerando que o sentenciado Leandro está preso por este processo (prisão preventiva), expeça-se recomendação ao estabelecimento em que se encontra recolhido, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação (art. 431, §1º das NSCGJ).

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário e bem apreendido nos autos – fl. 11 (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06).

Ademais, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo automotor VW/Golf, de placas JNU0C89, apreendido às fl. 11.

Isso porque, como já restou assentado, o automóvel era instrumento utilizado pelo acusado Leandro e o adolescente para a prática do tráfico de drogas. Inclusive suas chaves ficavam dentro da caixa de correio da Sra. Viviane, sobrinha da suposta proprietária do veículo Sra. Kátia, tia do réu Welker que é primo do réu Leandro, com quem foram encontradas as chaves do veículo retro, no dia da abordagem. De mais a mais, o STF já sedimentou o entendimento de que, para o decreto do confisco, é prescindível o emprego habitual do bem na prática criminosa ou a adulteração de suas características: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO.

DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

O condenado deve pagar custas processuais (art. 804 do CPP), nos termos da legislação estadual, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao réu Leandro, vez que beneficiário da justiça gratuita.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender o interesse do réu Leandro (fls. 51), tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Expeça-se certidão de honorários.

Publique-se e intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA